

<제3편 제1심의 소송절차.제6장 변론.제6절 변론기일에서의 당사자의 결석>

I. 당사자 결석의 요건

1. 필요적 변론기일일 것

- 당사자 결석의 효과가 발생하기 위해서는 원칙적으로 판결을 내리기 위해 반드시 열어야 하는 필요적 변론기일이여야 한다. 임의적 변론기일이나 변론준비기일 외의 단순한 사무 처리 기일 등에서는 민사소송법이 정한 결석의 일반적 효과가 발생하지 않는다.

2. 적법한 기일통지를 받고도 불출석할 것

- 당사자가 기일에 출석하지 않은 것이 법적 의미를 가지려면 해당 당사자에게 기일통지서가 적법하게 송달되었어야 한다. 송달이 부적법하거나 기일 지정에 오류가 있는 경우에는 불출석하더라도 결석의 효과를 귀속시킬 수 없다.

3. 불출석하거나 출석하여도 변론하지 않을 것

- 물리적으로 법정에 나타나지 않는 불출석뿐만 아니라, 법정에 출석하였더라도 사건 호명 시에 아무런 변론을 하지 않고 침묵하거나 변론을 거부하는 출석 무변론의 경우도 결석과 동일하게 취급한다. 이는 당사자가 소송 절차에 협조하지 않음으로써 발생하는 지연을 방지하기 위함이다.

II. 당사자 쌍방의 결석

1. 의의[민소법 제268조]

- 양쪽 당사자가 모두 적법한 통지를 받고도 기일에 출석하지 않거나 출석하여도 변론하지 않는 경우를 의미한다. 이를 쌍방 불출석 또는 쌍방 결석이라 하며, 소송의 진행 의사가 없는 것으로 간주하여 일정한 요건 하에 소 취하의 효과를 발생시킨다.

2. 취하간주의 요건

(1) 1회 쌍방 불출석

- 최초로 양 당사자가 불출석하면 법원은 다시 기일을 정하여 통지한다.

(2) 2회 쌍방 불출석

- 다시 정한 기일(또는 다음 기일)에도 양 당사자가 불출석하면 소송은 정지 상태에 놓인다.

(3) 1월 이내 기일지정신청의 부존재

- 2회 쌍방 불출석 후 1개월 이내에 어느 당사자도 기일지정신청을 하지 않거나, 기일지정신청에 의해 정해진 기일에 다시 양쪽이 불출석한 경우 소가 취하된 것으로 본다. 이를 취하간주라 한다.

3. 취하간주의 효과

- 취하간주의 요건이 충족되면 별도의 재판이나 선고 없이 법률상 당연히 소송이 종료된다. 이는 소 취하와 동일한 효력을 가지므로 해당 소송절차는 소급적으로 소멸한다. 다만, 본안에 대한 중국판결이 있을 후에 취하간주가 된 경우에는 재소금지의 원칙이 적용되어 동일한 소를 다시 제기할 수 없다.

4. 변론준비기일에서의 쌍방 불출석의 효과가 변론기일에 승계되는지 여부

- 변론준비기일에서의 쌍방 불출석 횟수와 변론기일에서의 불출석 횟수는 원칙적으로 합산되지 않는다. 즉, 변론준비절차에서의 태만은 해당 절차 내에서만 평가되어야 하며, 이를 변론기일의 불출석 횟수에 산입하여 취하간주의 효과를 발생시킬 수는 없다는 것이 통설적 견해이다.

III. 당사자 일방의 결석

1. 의의

- 한쪽 당사자는 출석하여 변론 준비를 마쳤으나, 상대방이 적법한 기일통지를 받고도 출석하지 않거나 변론하지 않는 경우를 말한다. 소송 절차의 공전(空轉)을 막기 위해 불출석한 당사자에게 일정한 불이익을 주어 절차를 진행한다.

2. 진술간주[민소법 제148조]

(1) 내용

- 출석하지 아니한 당사자가 미리 제출한 소장, 답변서 또는 준비서면이 있는 경우, 출석한 상대방이 변론을 하면 불출석한 당사자가 그 서면의 내용을 진술한 것으로 본다.

(2) 취지

- 구술주의 원칙에 의하면 기일에 진술하지 않은 서면은 소송자료가 될 수 없으나, 일방 결석 시 무조건 기일을 연기하면 소송이 무한정 지연될 수 있으므로 서면에 의한 진술을 의제하여 절차의 신속을 기하는 것이다.

(3) 요건 및 한계

- 서면이 제출되어 있어야 하며, 서면에 기재되지 않은 새로운 사실은 출석하지 않은 당사자에게 불리하게 주장될 수 없다. 또한, 공시송달에 의한 기일통지의 경우에도 적용되나, 이 경우 아래의 자백간주 규정과는 차이가 있다.

3. 자백간주[민소법 제150조, 제276조]

(1) 내용

- 당사자가 상대방의 주장 사실을 명백히 다투지 아니하거나 기일에 출석하지 아니한 경우, 그 사실을 자백한 것으로 보는 제도이다. 불출석한 당사자가 답변서나 준비서면조차 제출하지 않은 경우에 주로 발생한다.

(2) 공시송달과의 관계

- 기일통지가 공시송달에 의하여 이루어진 경우에는 자백간주의 규정이 적용되지 않는다. 공시송달은 당사자가 실제로 기일을 알지 못할 가능성이 크기 때문에, 단순히 불출석했다는 이유만으로 상대방의 주장을 인정한 것으로 간주하는 것은 가혹하기 때문이다.

(3) 효과

- 자백간주가 성립하면 법원은 증거조사 없이 해당 사실을 판결의 기초로 삼아야 한다. 이는 불출석한 당사자에게 매우 치명적인 불이익이 되므로, 소송대리인이 없는 당사자는 기일 준수에 주의를 기울여야 한다.

IV. 결론

- 변론기일에서의 당사자 결석에 관한 규정은 소송의 경제와 신속을 도모하고 당사자의 성실한 소송수행을 강제하기 위한 장치이다. 쌍방 결석 시의 취하간주는 소송 의사의 포기를 법률적으로 확정하여 불필요한 절차의 존속을 막으며, 일방 결석 시의 진술간주와 자백간주는 소송의 공전을 방지하여 출석한 당사자의 권리를 보호한다. 특히, 자백간주와 취하간주는 당사자의 실체법적 권리에 중대한 영향을 미치므로 법원은 기일통지의 적법성을 엄격히 심사하여야 한다. 한편으로 공시송달의 경우 자백간주를 배제하는 등의 보완책은 절차적 정의와 효율성 사이의 균형을 맞추려는 입법적 배려로 이해된다.

다. 당사자는 자신의 권리를 방어하기 위해 제출한 서면의 내용을 명확히 하고, 정해진 기일에 출석하여 변론함으로써 이러한 불이익을 예방하여야 할 것이다.